工期顺延的行权机制
——以《建设工程施工合同（示范文本）》工期顺延条款为视角

龚嫚嫚[1]　方泳桥[2]
1.湖北蕙风和律师事务所，湖北　武汉　430000；
2.东原房地产开发集团有限公司，湖北　武汉　430000

摘要：本文围绕《建设工程施工合同（示范文本）》中的工期顺延条款展开分析，比较了不同版本示范文本在工期顺延情形和程序要求上的差异，并强调承包人应准确适用相应示范文本下的工期索赔程序要求。同时，文章还探讨了发包人在工期顺延视角下的“行权”路径，指出在承包人起诉要求支付工程款的纠纷中，发包人主张承包人承担逾期竣工违约金的应以另诉或反诉方式提出，而非抗辩。整体而言，文章为工期顺延的行权机制提供了有益的分析和参考。

关键词：工期顺延；行权机制；《建设工程施工合同（示范文本）》

施工过程时常会发生影响工程进度的因素导致无法如期完工，而承发包人由于忽视办理工期顺延手续被高额索赔的案例屡见不鲜[1]。鉴于目前国内采用的施工承包合同示范文本、工程总承包合同示范文本对于工期顺延的约定存在差异，承发包人在履约过程中务必认真阅读合同条款并严格按约履行，才可避免由此产生的不必要损失。笔者拟结合国内几个常用示范合同文本工期顺延条款进行比较分析。

一、实体上允许办理工期顺延

承包方申请工期顺延，首先应做到有理有据，即明确哪些情形承包方有权提出顺延申请[2]。对此，不同的示范文本在约定上有所异同。

（一）1999 年版施工合同示范文本

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）（已废止，简称《1999 版示范文本》）在通用条款第十三条第一款中明确了下列情形属于可顺延工期的情形：第一，发包人未按约提供图纸及开工条件；第二，发包人未按约支付工程款（含预付款、进度款等）；第三，工程师未按约提供所需指令、批准等，影响施工推进；第四，设计变更和工程量增加；第五，非承包人原因（一周内）停电、停气、停水造成停工累计超过 8 小时；第六，不可抗力；第七，专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。此外，通用条款第六条第二款的工程师指令错误、第十八条的隐蔽工程重新检验合格、第十九条第五款的因设计原因试车达不到验收要求、第二十七条第四款的发包人供应材料和设备的时间晚于约定时间、第四十三条第一款的发现和保护文物以及第四十三条第二款的发现地下障碍物等，都属于可以顺延工期的情形。

（二）湖北 2007 年版施工合同示范文本

《湖北省建设工程施工合同》（EF—2007—0203）（已废止，简称《2007 版湖北省示范文本》）基本覆盖了《1999 版示范文本》关于工期顺延适用情形的约定，此外还新增了“发包人的风险事件”“非因承包人失误、违约的其他情况”“紧急情况时承包人采取措施”“非承包人原因造成的暂停施工”这几种允许工期顺延的情形。尤其是“发包人风险事件”将发包方的过错、过失及其它不可预见的风险都纳入了工期顺延的情形，发包方申请工期顺延的范围得到了扩大。

（三）2013 年版、2017 年版施工合同示范文本

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）（已废止，简称《2013 版示范文本》），《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）（简称《2017 版示范文本》）首次将工期顺延定义为“工期索赔”，后者在工期顺延的适用情形上更为细化，除了在通用条款第第七条第五款第一项、第十七条第三款第二项详细规定了因发包人原因可进行工期索赔的情形，亦新增了前文两个示范文本所没有之新内容。其中“不利物质条件”“异常恶劣的气候条件”“因法律变化工期可顺延的情形”是该示范文本的亮点。“不利物质条件”包括《1999 版示范文本》中提到的“地下障碍物”“文物化石”等方面，但其范围又不限于以上内容；“异常恶劣的气候条件”对于尚不构成不可抗力的气候条件所造成的工期延误允许进行索赔。此外，鉴于《2017 版示范文本》通用条款对“不利物质条件”和“异常恶劣气候条件”的具体情形未进行详细的规定，笔者

中国知网　https://www.cnki.net

建议承包人应在专用条款中进行完善。但值得注意的一点是前文两个示范文本中已规定“停水、停电、停气造成的停工”属于允许顺延的情形，但《2017 版示范文本》却未有涉及。

（四）2020 年版建设项目工程总承包合同示范文本

《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF—2020—0216）（简称《2020 版示范文本》）系住建部基于《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF—2011—0216）修订而成。其区别于传统的施工总承包合同文本，适用于工程总承包活动。该文本除在通用条款第八条第七款第一项详细规定因发包人原因可进行工期索赔（包括发包人聘请的第三方原因导致的工期延误），及在通用条款第八条第七款第四项约定异常恶劣的气候条件（仍需在专用条款中界定何种情形属于异常恶劣气候，否则可能发生约定不明的法律后果）也适用于工期顺延之外，又新增了“行政审批迟延情形”，即在通用条款第八条第七款第三项约定因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延（该情形或基于工程总承包项目的特殊性，工程总承包项目的承包范围包括设计任务，项目开工的前提条件之一是获得建设工程规划许可证，而承包人编制完成施工图纸，待图审通过后才能申请办理建设工规证及施工许可证，行政部门的审批或将存在一定延迟进而影响到项目开工，但审批的延迟不应全归责于承包单位）。

以上即目前国内部分示范文本对工期顺延情形的约定，关于权利义务的分配上较为均衡。但示范文本系推荐使用，而非强制性使用。在实务过程中基于发包人的强势地位未必会采用以上示范文本（尤其部分大型企业有自行拟定的成熟合同范本），或在示范文本专用条款中作出强势约定，例如约定由承包人承担工期无限风险责任，此项约定实系变相压缩工期而存在显失公平，最终未必能得到法院认可。

此外，实操中部分承包合同关于工期顺延的情形约定不明，尽管《中华人民共和国民法典》（简称《民法典》）对于交易习惯并未明确定义，但此前《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》（已废止）第七条对“交易习惯”有定义：交易习惯指不违反法律、行政法规强制性规定，为交易对方订立合同时所知或应知的在交易行为当地或者某一行业、某一领域通常采用的做法；或为当事人双方经常使用的习惯做法。故示范文本关于工期顺延情形的约定亦有可能因被认定为交易习惯而得到适用。

二、程序上按约申请工期顺延

承包人申请工期顺延应准确适用示范文本下工期索赔的程序要求，防止因逾期索赔导致索赔不能，而发包单位也应注重合同文本的约定，防止因逾期答复索赔而产生的额外损失[3]。

（一）1999 年版施工合同示范文本

第一，依据《1999 版示范文本》，在前文约定情形发生后 14 天内，承包人应就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到前述书面报告后 14 天内应予以确认，逾期既不确认也不提出修改意见，则视为同意顺延工期。

第二，承包人因《1999 版示范文本》通用条款第十三条第一款约定之外的情形需要申请工期顺延和经济补偿的，应遵循如下程序进行书面索赔：一是承包人在索赔事件发生后 28 天内，应先向工程师发出索赔意向通知；二是在索赔意向通知发生之后 28 天内，承包人应向工程师提出索赔报告及有关资料；三是在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内，承包人应给予答复或要求进一步补充索赔理由和证据；四是工程师在收到承包人送交的第三项资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，则视为已经认可该项索赔；五是索赔事件持续进行时，承包人应阶段性向工程师发出索赔意向，待索赔事件终了后 28 天内，承包人应向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。

（二）2007 年版施工合同示范文本

《2007 版湖北省示范文本》对于工期顺延的程序要求与《1999 版示范文本》较类似，主要是对于具体申请期限进行修改，其中承包人因不可抗力和其他情形而申请顺延的时限为事件发生后 14 天内。对于持续性事件，承包人应每隔 7 天向监理工程师提交事件发生的详细资料。逾期申请顺延和提供资料的，监理工程师可拒绝做出任何延期的决定，但造价或监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后的 28 天内如未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为已认可该项索赔。

（三）2013 年版、2017 年版施工合同示范文本

《2013 版示范文本》《2017 版示范文本》在工期索赔的程序上更为规范。除了应按《1999 版示范文本》先后提交索赔意向通知书、正式索赔报告及最终索赔报告外，对于持续性事件，二者和《2007 版湖北省示范文本》一样，均要求承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知。此外，笔者认为如下两点应该重点注意：第一，前述示范文本均规定了发包人逾期处理索赔报告的法律后果，其中《2013 版示范文本》《2017 版示范文本》均有规定监理人在收到索赔报告或进一步证明材料后的 28 天内未进行答复的，则视为发包人认可承包人的索赔要求；第二，二者与《2007 版

中国知网 https://www.cnki.net

湖北省示范文本》都规定了“逾期失权制度”，即承包人应在知道或应当知道索赔事件后的约定时间内向发包人或监理人申请索赔，否则将丧失索赔权。但与此不同的是《1999 版示范文本》仅约定承包人须在可顺延事项发生后 14 天内提出工期顺延申请，对于逾期申请工期顺延的法律后果却没有规定。而司法实践中只要承包人在诉讼时效内提起诉讼，法院也通常会支持顺延主张。

（四）2020 年版建设项目工程总承包合同示范文本

有关工期顺延的程序义务事宜，《2020 版示范文本》基本沿袭了《2013 版示范文本》和《2017 版示范文本》的内容，具体体现在“逾期索赔”及“逾期答复”的法律后果上。“逾期索赔”方面在通用条款第十九条第一款中约定“索赔方未在索赔事项发生后 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加 / 减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利”。“逾期答复”方面则在通用条款第十九条第二款中约定“工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔”。

此外，该文本项下约定的接受承包人索赔的系“工程师”，与国际咨询工程师联合会（简称 FIDIC）中的工程师形式不同，国内工程总承包项目中的“工程师”特指受建设单位委托，按照法律规定和业主的授权进行合同履行管理、工程监督管理工作的法人或其他组织。《2020 版示范文本》通用条款第三条第三款第一项则直接约定“如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外”，有关工程师的功能角色类似于传统施工总承包项目的监理工程师但又不尽相同（工程师监督管理的范围相对更全面，包括设计、采购、施工等多环节）。

综上，《2020 版示范文本》在条款设置上越发科学严谨。但值得一提的是“程序义务”的适用方面，法院在援引时应格外严谨，不同于工期顺延的情形，未做约定的可依交易习惯（如行业标准、通用示范文本等）而定。而该机制的适用前提系已明确约定“逾期失权”，如合同中仅约定承包人应在约定期限内提出工期顺延申请但未约定失权的法律后果则不能适用。

三、工期顺延视角下的发包人“行权”路径

司法实践中，时常会发生承包人应按约承担逾期竣工违约金的情形。而在承包人起诉要求发包人支付工程款的施工合同纠纷当中，发包人通常会抗辩应自工程款中扣减逾期竣工违约金。此时，关于发包人的逾期竣工违约金主张是应以抗辩还是反诉的方式提出时有争议，甚至出现审判机构对此无法准确甄别的情形。部分法官由于担心如以反诉的方式与本诉合并审理会影响案件审限，有时会引导当事人另诉或在本诉中以抗辩的方式合并处理[4]。更有甚者，还出现工程造价鉴定机构直接就工期违约金的金额进行认定的情形，即所谓的“以鉴代审”。

而有关反诉与抗辩的行使方式，司法实践中判断的参考标准主要体现为两方面：第一，被告主张是否超越原告诉讼请求范围；第二，被告对原告是否具有独立的请求给付内容。尤其是后者，是被告积极主张权利的体现。《民法典》第八百零一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的……经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”而发包人主张承包人承担违约责任或赔偿损失（包括工程质量不合格的损失索赔、承担返修义务或赔偿损失、逾期竣工的违约索赔），因该主张明显超出原告的诉讼请求范围，具有独立的给付请求内容，通常应作为反诉与本诉合并审理，而不能允许发包人以此为由抗辩。而若发包人仅以工程质量问题提出“减少支付工程款”或“因原告拒绝维修工程而另行委托他人修复后，主张抵扣修复费用的”，则可以抗辩的方式提出主张。因此，无论是发包人或承包人均应结合具体情形有针对性地进行抗辩、反诉或另诉，否则或将出现“殊途而不同归”的情形。

四、结语

本文所论述的示范文本在适用的情形和程序上各有不同，为了防范发包人及承包人法律风险，笔者建议发承包人的项目管理人员均应认真研究合同文本及做好合同交底工作，在实施工程项目管理过程中，各方除了应及时按合同约定提出索赔外，还应注意索赔及反索赔证据原件的搜集、整理和归档（包括但不限于变更指令、会谈纪要、工程联系函、施工日记等），所有发出函件均应做好签收、存档准备，以确保索赔证据的真实性、时效性，毕竟证据才是索赔（包括反索赔）胜诉的关键所在。

参考文献

[1] 杨学建.建设工程施工合同纠纷存在的问题与策略应对[J].法制博览，2022(8)：97-99.

[2] 刘黎虹，刘晓旭，董晶.建设工程招投标与合同管理：第 2 版[M].北京：化学工业出版社，2022：270.

[3] 覃孝辉.建设工程施工合同示范文本的有效运用[J].价值工程，2018，37(20)：58-59.

[4] 刘长秀.我国建设工程施工合同示范文本与 FIDIC 合同比较研究[D].南京：东南大学，2018.

中国知网 https://www.cnki.net